

1501597-49.2020.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... Habeas Corpus. Constitucional, penal e processual penal. Tráfico de entorpecentes. Aplicação da Lei n. 8.072/90 ao tráfico de entorpecentes privilegiado: inviabilidade. Hediondez não caracterizada. Ordem concedida. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

1ª Vara Judicial

Av. Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar - SP - cep 07786-520

1501597-49.2020.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501597-49.2020.8.26.0544

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO WILLIAM DE JESUS PASSOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Vistos.

O Ministério Público, por intermédio de seu Ilustre Representante Legal, em exercício neste juízo e no uso de suas atribuições legais, com base no incluso auto de inquérito policial, ofereceu denúncia em face de RICARDO WILLIAM DE JESUS PASSOS, devidamente qualificado nos autos deste processo crime, dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, pela prática dos fatos delituosos, narrados na peça vestibular, nos seguintes termos:

Consta da denúncia que, no dia 31 de julho de 2020, por volta das 18h32, na Rua Bocaína, 318, Gato Preto, nesta cidade e comarca de Cajamar-SP, RICARDO WILLIAM DE JESUS PASSOS trazia consigo, para fins de traficância, sem autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 7 pedras de crack e 33 porções de cocaína, substâncias causadoras de dependência química e psíquica.

Convertida, em sede de plantão judiciário, a prisão em flagrante do denunciado em prisão preventiva em 01/08/2022 (f. 47-50).

Laudo de exame químico de entorpecente acostado (f. 128-130).

A denúncia foi recebida em (f. 93-94), o réu foi regularmente citado (f. 132) e ofereceu defesa prévia (f. 139).

Em reanálise da prisão por força do art. 316, parágrafo único, do CPP, concedeu-se liberdade provisória ao acusado (fls. 166/167).

Rejeitada a hipótese de absolvição sumária (f. 145), prosseguiu-se à fase instrutória, momento em que foram ouvidas testemunhas.

O réu não compareceu ao ato, tendo sido decretada sua revelia, na forma do art. 367 do CPP.

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram. Acusação e Defesa se manifestaram em alegações finais orais.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando apurar a responsabilidade de RICARDO WILLIAM DE JESUS PASSOS pela prática do fato delituoso disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

De fato, assiste razão ao Ministério Público.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está comprovada pelo auto de prisão em flagrante do réu (f. 1), boletim de ocorrência (f. 5-7), auto de exibição e apreensão (f. 8), auto de constatação da natureza tóxica (f. 20-24) e laudo pericial químico de entorpecente (f. 128-130), que atestou que a substância encontrada se tratava de cocaína, que é de uso proscrito no Brasil.

A autoria, por seu turno, é inconteste, por intermédio da prova oral coligida em Juízo, e é atribuída ao acusado RICARDO WILLIAM DE JESUS PASSOS.

Inquirida, a testemunha Eduardo Martin, guarda municipal, disse que em patrulhamento pelo local, que é conhecido pela venda e consumo de drogas, depararam-se com o acusado agachado, escavando uma sacola do chão. Abordado, localizaram R\$ 20,00 em dinheiro no bolso, além de crack e cocaína na sacola. Indagado, afirmou que é morador do local e usuário de cocaína, sendo que o sistema de tráfico era agora por "delivery", em que o próprio comprador retira os entorpecentes, pagando para terceiro, que levaria ao traficante. Não conhecia o acusado anteriormente. Não indicou a pessoa a quem teria dado o dinheiro e na Delegacia ficou em silêncio. Vestia uma bermuda, que abrigava o dinheiro apreendido.

A testemunha Heleno Numereano da Silva, guarda municipal, relatou que havia quantia em dinheiro no bolso do acusado e uma quantidade de drogas. Lembra-se que eram mais de 30 embalagens de droga. Já o haviam abordado uma vez no mesmo local. O acusado alegou que estava se servindo da droga, de um pino, salvo engano. O conjunto de entorpecentes não lhe pertencia. Não forneceu maiores detalhes.

Inicialmente, não há porque se desconfiar da palavra dos guardas municipais, que, na qualidade de agentes públicos, possuem fé pública, gozando da presunção iuris tantum de veracidade, qualidade essa que não foi afastada pela louvável defesa.

Dar-se crédito àquele que é detido em plena e objetiva ação delituosa, em detrimento das palavras dos agentes da lei, que cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria inverter de tal forma os valores que se deixaria em descrédito a própria Justiça.

Saliento que para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, que já se consuma pelo fato de o agente manter em depósito e trazer consigo drogas para entrega e consumo de terceiros, o que ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido, cito decisão do colendo Supremo Tribunal Federal: "A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

Ademais, é imperiosa a necessidade de o julgador estar sempre atento e dedicado às teses defensórias, no entanto, no caso em análise, as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto que representam sua irreabilidade.

Nada indica que os policiais tenham criado uma situação para acusar falsamente o acusado. A presunção iuris tantum de que agiram escorreiamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada.

Registre-se, ademais, que a jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada a má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou a respeito.

Outrossim, o fato de o acusado ser usuário de entorpecente não afasta a possibilidade do delito de traficância.

Pelo contrário, não é raro que usuários passem também a comercializar entorpecentes

justamente para garantir o próprio vício, acrescentando-se, por oportuno, que uma conduta não exclui a outra: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (RJTJSP 101/498). Ademais, como também reconhecem os tribunais: "Não cabe a desclassificação do delito de tráfico ilícito de substância entorpecente, para o delito de uso indevido, quando ausente a prova, a cargo da defesa, da exclusividade do uso próprio" (RT 710/325).

A versão apresentada aos guardas municipais, de que estava apenas comprando drogas em sistema de "delivery", com a devida vênia, é de todo inverossímil e fantasiosa, e restou ilhada do conjunto probatório.

Ademais, sequer compareceu em juízo para reafirmar e comprovar sua narrativa, conduta que não se espera de quem se afirma inocente.

Como bem afirmado pelo Parquet em memoriais, não há qualquer resquício de prova a corroborar a tese defensiva tecida informalmente às testemunhas.

Desta forma, não há qualquer elemento indicativo que pudesse colocar em cheque a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

À guisa de arremate, os elementos objetivos, subjetivos e normativos do tipo estão tranquilamente comprovados nos autos: a quantidade de entorpecente (7 porções de crack e 33 porções de cocaína); o modo de acondicionamento (invólucros plásticos, embalados individualmente e prontos para o comércio); a questionável a origem financeira dos valores apreendidos, eis que nenhuma prova idônea foi trazida aos autos para comprovar sua licitude; o local onde se deram os fatos (conhecido ponto de tráfico de drogas); revelam que se tratava sim da prática do tráfico ilícito de entorpecentes, visando o consumo de terceiros, nos termos do parágrafo 2º, do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

E pela lição de Júlio F. Mirabete, "indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado" (in Processo Penal - 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 344).

Destarte, o conjunto probatório é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação pelo crime de tráfico.

Sob essa ótica, passo a individualizar a pena, de modo fundamentado e seguindo os parâmetros do artigo 68, caput, do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase, analisando-se as circunstâncias judiciais descritas nos artigos 42 da Lei 11343/06 e 59, caput, do Código Penal, as circunstâncias não são favoráveis. Isso porque, apesar de tecnicamente primário, o comércio de substância altamente letal ao ser humano (crack) impõe uma elevação nas penas bases, no montante de 1/6, resultando-se em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, não vislumbro a presença de atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase de cálculo penal, considero aplicável o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, vez que o acusado é primário, portador de bons antecedentes e não há nenhum elemento indicativo de que integre organização criminosa.

No entanto, para evitar bis in idem deixo de valorar a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos. Nesse aspecto: "Recurso extraordinário com agravo.

Repercussão Geral. 2. Tráfico de Drogas. 3. Valoração da natureza e da quantidade da droga apreendida em apenas uma das fases do cálculo da pena. Vedação ao bis in idem. Precedentes. 4. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para determinar ao Juízo da 3ª VECUTE da Comarca de Manaus/AM que proceda a nova dosimetria da pena. 5. Reafirmação de jurisprudência. Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencidos os Ministros Luiz Fux e Marco Aurélio. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencidos os Ministros Luiz Fux e Marco Aurélio. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencidos os Ministros Luiz Fux e Marco Aurélio." (Brasília - residência -, 1º de

abril de 2014. Ministro MARCO AURÉLIO).

Desta feita, aplico o redutor no patamar máximo de 2/3, totalizando 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 194 dias-multa, penas que torno definitivas, à míngua de outros elementos modificadores.

Tendo em vista que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde as práticas delituosas.

Em atenção aos artigos 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Nesse ponto, ressalto recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o tráfico de drogas, na forma privilegiada não possui natureza hedionda:

"Ementa: Habeas Corpus. Constitucional, penal e processual penal. Tráfico de entorpecentes. Aplicação da Lei n. 8.072/90 ao tráfico de entorpecentes privilegiado: inviabilidade. Hediondez não caracterizada. Ordem concedida. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida." (HC 118.533, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.09.2016).

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, verifico que o regime inicial aberto se mostra mais adequado, em razão da quantidade de pena aplicada ao réu, da primariedade e conduta social e personalidade favoráveis, não obstante a alta lesividade da substância entorpecente apreendida.

E, pelos mesmos motivos, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direito, nos termos do artigo 44 e parágrafos do Código Penal, quais sejam: prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo período da privação de liberdade e à razão de uma hora por dia de condenação, a ser indicada pelo juízo da execução; e multa de 2 salários mínimos vigentes, a ser corrigida monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo à época da execução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão condenatória deduzida na denúncia para CONDENAR o réu RICARDO WILLIAM DE JESUS PASSOS, já qualificado nos autos desse processo crime, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 194 dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 de salário mínimo vigente à época dos fatos corrigidos monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde as práticas delituosas; substituída a primeira por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo período da privação de liberdade e à razão de uma hora por dia de condenação, a ser indicada pelo juízo da execução; e multa de 2 salários mínimos vigentes, a ser corrigida monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo à época da execução.

Não estando configurados os requisitos ensejadores da custódia cautelar do acusado e tendo em vista o quantum da pena e o regime inicial de cumprimento, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ante à inexistência de elementos que viabilizem a fixação de um patamar mínimo de reparação dos danos causados pela infração e diante da ausência de pedido.

Em que pese a inserção pelo legislador do quanto trazido pelo art. 387, § 2º, do CPP, entendo inviável competência concorrente entre o Juízo do conhecimento e o Juízo da execução, sendo que somente a este é viável a apreciação de eventual detração em caráter originário, cotejando o requisito objetivo conjuntamente com o de viés subjetivo.

Condene o réu nas custas processuais, ressalvada a hipótese de ser beneficiário de assistência judiciária gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC.

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente ação criminal, tomem-se as seguintes providências:

Expeça-se a competente guia de recolhimento definitiva;

Oficie-se o órgão competente para o recolhimento dos valores monetários e bens apreendidos, de acordo com artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/06;

Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova, que, após o trânsito em julgado, também deverá ser incinerada;

Em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre a condenação do réu.

Intime-se o(a) sentenciado(a) para efetuar o recolhimento do valor da pena da multa e das custas processuais, no valor de 100 UFESP's, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Decorrido o prazo supra sem que o(a) sentenciado(a) tenha recolhido os valores da multa e/ou das custas processuais, certifique a serventia o ocorrido, expeça-se certidão para fins da inscrição em dívida ativa e comunique-se o ocorrido à Vara de Execuções competente para executar às penas impostas a(o) sentenciado(a);

Arbitro os honorários do(a) defensor(a) do(a) acusado(a) no patamar máximo da tabela do convênio firmado entre a DPE/SP e OAB/SP. Expeça-se a certidão, observando-se que deverá o(a) Defensor(a) acompanhar sua confecção, imprimi-la e encaminha-la para a Defensoria.

A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários, devendo ser instruída com os documentos pertinentes.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

Publique-se.

Cajamar, 16 de março de 2022.